

1500827-57.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que o réu estava envolvido com o tráfico de entorpecentes.

Com efeito, o ato de consumir e negociar drogas em plena via pública somado à conduta de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico.

Cabe frisar, ainda, que a apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500827-57.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500827-57.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Roberto de Jesus Oliveira

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Paulo Roberto de Jesus Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público porque às 02h15 de 27 de junho de 2022, na Avenida Vila Velha, próximo ao n. 1.117, Estiva, nesta cidade e comarca de Taubaté, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, trazia consigo para entregar a consumo de terceiros 2,44 gramas de cocaína sob a forma petrificada (crack), substância determinante de dependência física e psíquica.

Segundo consta na denúncia, em patrulhamento de rotina, agentes públicos visualizaram o réu e a testemunha Laércio sentados na via pública, em frente ao numeral 1.117. Ao notar a presença da guarnição, o réu dispensou um objeto no chão, o qual foi posteriormente identificado como sendo 25 pedras de crack, embaladas individualmente para entrega a terceiros consumidores.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.

11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 88/91.

Citado (fls. 125), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 108.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público defendeu a parcial procedência da ação penal. Postulou a desclassificação da conduta para se adequar ao crime previsto no artigo 33, § 2º, da Lei de Drogas. Destacou a prova oral colhida em juízo. Argumentou que a suposta negociação de drogas se mostrou duvidosa e há prova de que houve oferecimento de entorpecentes como cortesia para uso comum. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela natureza da droga e pelos antecedentes criminais. Sustentou que a confissão pode ser compensada com a reincidência. Pediu imposição de regime inicial semiaberto. Combateu a possibilidade de substituição da pena por reprimenda restritiva de direitos.

A Defesa suscitou a ilicitude da abordagem dos agentes públicos por ausência dos requisitos previstos no artigo 244, do Código de Processo Penal e por falta de competência dos guardas civis municipais. No mérito, defendeu a absolvição do réu por falta de provas. Argumentou, ainda, que o pleito de desclassificação formulado pelo Ministério Público não se mostra possível, por ausência de aditamento da denúncia. Pontuou que o réu não praticou qualquer verbo-núcleo do tipo tardiamente imputado pela acusação. Subsidiariamente, pugnou a imposição de pena mínima com compensação entre eventuais agravantes e a confissão. Rogou pela fixação de regime inicial aberto e a concessão de liberdade.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preliminarmente, a Defesa sustenta a nulidade do feito ab initio, pois a Guarda Civil Municipal de Taubaté não possui atribuição para abordar o réu em via pública, tampouco tinha motivos que permitissem a intervenção no caso concreto. Dessa forma, entende que a prova não pode ser utilizada em desfavor do réu, por ser ilícita.

A argumentação, com a devida vênia, não convence, pois, do conjunto probatório se verifica que a diligência da guarda municipal não extrapolou suas competências e atribuições constitucionais e legais.

Nos termos da Lei 13.022/14 e da Lei Complementar municipal nº 391/2016, compete às guardas municipais “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”.

Cediço que o réu e o outro indivíduo foram abordados na via pública, pois, assim que percebeu a aproximação da viatura policial, o acusado dispensou um objeto ao chão. Percebe-se, assim, que a abordagem foi motivada pelo comportamento do próprio réu, que tentou se livrar da sacola que carregava na mão assim que notou a presença dos guardas civis, situação suficiente a demonstrar a fundada suspeita de que ele estivesse na posse de objeto proibido (artigo 244, do Código de Processo Penal).

Importante pontuar que os guardas civis não estavam apurando qualquer denúncia de

tráfico de drogas. Ao contrário, conforme narrado pelos guardas, estavam efetuando patrulha rotineira para preservação de bens municipais, no caso, próximo a uma escola municipal de educação infantil, agindo dentro da competência a eles atribuída. Verifica-se, assim, que os guardas não efetivaram nenhuma medida investigativa, mas tão somente efetuaram a prisão do acusado, que estava em estado de flagrância.

Evidente que os guardas tinham fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas consistentes na tentativa de em dispensar, diante deles, as drogas que trazia consigo, que o réu estava envolvido com o tráfico de entorpecentes.

Com efeito, o ato de consumir e negociar drogas em plena via pública somado à conduta de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico.

Cabe frisar, ainda, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do réu, uma vez que a sacola com drogas havia sido por ele dispensada em via pública imediatamente antes da abordagem, de modo que não estava mais junto ao seu corpo (STJ, HC 742.815/GO, Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.08.2022).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão sobre o tema, permitindo, inclusive, a prisão dos infratores:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (HC 129.932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010)

A prova constante dos autos é suficiente a demonstrar que havia elementos seguros, objetivos e racionais a justificar a abordagem. Presente estava, ali, a justa causa, consubstanciada no estado de flagrância do acusado vislumbrado pelos agentes públicos.

A materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), termo de depoimento (fls. 2/3), termo de declarações (fls. 4), termo de interrogatório (fls. 6), auto de qualificação (fls. 12), auto de exibição e apreensão (fls. 31), laudo pericial (fls. 33/35) e depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Rosimeire Leila Cascalde asseverou que a equipe estava passando pelo local para atender a um alarme disparado em uma creche. Asseverou que, ao perceber a passagem da equipe, o réu jogou um objeto ao chão. Diante da conduta, decidiu abordar o acusado e recolheu as drogas que ele havia dispensado. Indagado, o réu disse que as drogas não eram destinadas ao comércio. Todavia, a testemunha que estava na companhia do acusado disse que estava no local para comprar drogas do acusado.

A testemunha Devanir Moreira dos Santos, ouvida em juízo, informou que estava em deslocamento pela região dos fatos quando avistou dois indivíduos em um

estabelecimento. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu jogou um objeto ao chão, o que ensejou a abordagem. Recolheu as drogas dispensadas pelo réu. Indagado, o réu disse que era apenas usuário de drogas. Questionado o segundo indivíduo, ele disse que trocaria sua corrente por drogas. Não conhecia o acusado.

Laércio da Silva Ferreira disse que entrou em contato com o indivíduo para comprar drogas, mas estava apenas com uma corrente. Disse que não tinha dinheiro e queria "empenhar" a joia. Nesse ínterim, enquanto negociava a troca da droga pela corrente que carregava, alguns guardas municipais se aproximaram e efetuaram a abordagem. Aduziu que o réu mantinha as drogas no chão quando a abordagem foi iniciada. Asseverou que é dependente químico e teve uma recaída na data dos fatos. Não costumava ir àquele ponto de venda de drogas. Sequer conseguiu entregar a corrente para receber as drogas, pois a abordagem ocorreu antes do término da troca. Aduziu que recebeu um pedaço da droga para consumir no local como forma de cortesia. Permaneceu no local na companhia do réu pelo tempo de consumir a droga. Não viu outras pessoas se aproximarem enquanto ali permaneceu. Asseverou que havia um rapaz que costumava pegar drogas naquele local para ela. Informou que um morador de rua o levou até o local dos fatos naquele dia.

Interrogado, o réu disse que é usuário de drogas. Confirmou que estava no local da abordagem na posse de drogas, as quais eram destinadas ao seu consumo. Estava consumindo drogas ali, pois o local era comumente utilizado por outros usuários. Informou que Laércio se aproximou e pediu para trocar uma corrente por porções de crack. Negou que estivesse vendendo drogas. Contou que havia vendido alguns objetos para comprar as cerca de vinte pedras de crack que trazia consigo. Comprou trinta pedras de crack por cem reais na região denominada Ipanema, na mesma data dos fatos. Admitiu que forneceu drogas para a testemunha Laércio tão somente para consumo conjunto.

Bem provadas a autoria e a materialidade do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra em ao menos um dos verbos-núcleo do tipo, notadamente trazer consigo e entregar a consumo de terceiros drogas, resultando configurada a tipificação do crime em comento.

A própria prisão em flagrante demonstra que o réu carregava consigo 25 pedras de crack, droga que estava sendo negociada com um usuário de entorpecentes no exato momento em que os guardas civis passavam pelo palco delitivo.

Somada a esse fato, tem-se a segura narrativa fornecida pelo usuário de drogas que estava no local, corroborando a narrativa fornecida pelos guardas responsáveis pela abordagem do réu e da testemunha, além da localização das drogas em uma sacola dispensada naquele instante.

Narram os agentes públicos que, durante diligências de rotina pela região dos fatos, viram duas pessoas juntas, sendo que o réu, apressadamente, tentou se desfazer de uma sacola, atitude suspeita que ensejou a abordagem. Submetido a revista, o réu foi flagrado na posse de drogas, que estavam escondidas na indigitada sacola. Destacaram que as porções de crack estavam sendo negociadas para venda ao outro indivíduo abordado. Aduziram que o réu confessou a propriedade das drogas.

Cumpra destacar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado.

Relataram como ocorreu a prisão e as circunstâncias em que foram encontradas as drogas, que estavam armazenadas nas vestes do acusado.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes de segurança, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os guardas têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra das testemunhas, que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia seus agentes para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Ouvida perante a autoridade policial, a testemunha Laércio disse que é usuário de crack e foi ao local na data dos fatos para comprar droga para seu próprio consumo. Informou que um morador de rua que fica próximo à sua residência o levou ao local dos fatos e disse que o réu ali vendia drogas. Foi comprar crack do acusado. Alegou que trocaria sua corrente banhada a ouro por quatro pedras de crack com o réu. Ocorre que, antes de efetivar a transação, uma viatura da GCM se aproximou, motivo pelo qual o acusado jogou ao chão drogas que trazia em suas mãos. Disse que ambos foram abordados, mas não tinha nada de ilícito consigo.

Dessa forma, com base na prisão em flagrante e na robusta prova testemunhal, especialmente do usuário comprador de drogas, não há qualquer dúvida acerca do fato e da responsabilidade do réu pelo evento criminoso.

A prova é certa, segura e dá conta do cometimento do crime pelo réu, que deve responder pelo ilícito praticado.

Estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, da Lei Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza das drogas e suas quantidades não pesam em desfavor do réu, porquanto se trata de quantidade não excessiva que não justifica o aumento da pena base. Anote-se que, em peso líquido, foram apreendidos 2,44 gramas de crack (fls. 33/35).

Na aferição dos antecedentes criminais, utilizo a condenação definitiva no processo n. 0011197-60.2004.8.26.0050 para aumento da reprimenda (fls. 58/75).

A personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo “A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena”, da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a

mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base.” (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie. Não há elementos para valorar sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são afetos ao crime, nada havendo a valorar. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, acresço 1/3 (maus antecedentes e personalidade negativa) ao patamar mínimo e fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, verifico que o réu é multirreincidente, como se infere pela certidão de antecedentes criminais de fls. 58/75 (processos n. 1500743-61.2019.8.26.0618 e 0000999-49.2017.8.26.0618). Nesse passo, aumento a reprimenda em 1/6, que assim passa a totalizar o valor de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Na terceira fase, não se vislumbram presentes causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Em atenção à quantidade de pena imposta ao réu, aos maus antecedentes e à personalidade desvirtuada, não há possibilidade de fixação de regime inicial

distinto do fechado, nos termos do artigo 33, §§ 3º e 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Trata-se de condenação por tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado, cabendo ser ressaltado que por se cuidar de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime mais severo.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime e a reincidência do réu, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Inadmissível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Mantenho a prisão cautelar, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de forma que, reputando presente a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos réus, nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso

cautelamente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos com o réu (fls. 87) em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse daquele.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Paulo Roberto de Jesus Oliveira à pena 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder o pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA